

UNIDAD 8.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Concepto

Es el acuerdo de voluntades, generador de obligaciones y derechos, celebrado entre un órgano del Estado, en ejercicio de las funciones administrativas que le competen, con otro órgano administrativo o con un particular o administrado, para satisfacer finalidades públicas (Marienhoff).

Caracteres. Régimen jurídico

El contrato administrativo tiene elementos comunes al contrato de derecho privado pero con variantes que dependen del contenido, del fin, de los distintos intereses que afecta y de su régimen jurídico propio.

Los caracteres son 4:

- **Formalismo:** En los contratos administrativos se supedita su validez y eficacia al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones vigentes en cuanto a la forma y procedimiento de contratación. Estas formalidades se dan a través de una serie de actos preparatorios del contrato.
- **Prerrogativas de la Administración:** Debemos tener presente que tanto los principios de la autonomía de la voluntad como la igualdad jurídica de las partes, quedan subordinadas en los contratos administrativos. La libertad de las partes queda circunscripta:

- por la norma que fija el procedimiento para elegir al contratista
- a la aprobación o autorización legislativa o administrativa
- a la subordinación del objeto al interés público

El co-contratante no tiene, en principio, libertad de disentir respecto de las condiciones del contrato, sino que sólo podrá aceptarlas o rechazarlas, prevaleciendo siempre el interés público por sobre los intereses privados

Estas prerrogativas se manifiestan en:

- Desigualdad jurídica
- Cláusulas exorbitantes.
- **Derechos y obligaciones personales (intuito personae).**
- **Efectos respecto de terceros:**

- ✓ En el derecho privado, los contratos no pueden ser ni opuestos a terceros ni invocados por ellos (art 1021 CCyC).
- ✓ Por el contrario, en el derecho público, los contratos de la Administración pueden, en ciertos casos, ser opuestos a terceros: sus efectos se extienden a terceros que no son partes. Ej: en las concesiones de obra pública, el concesionario tiene derecho a exigir de ciertos terceros el pago proporcional de la obra, lo que conocemos como contribución de mejoras.
- ✓ A su vez, los terceros pueden invocar el contrato administrativo, exigiendo que el concesionario preste el servicio correspondiente en la forma pactada.

Régimen de contratación del Estado.

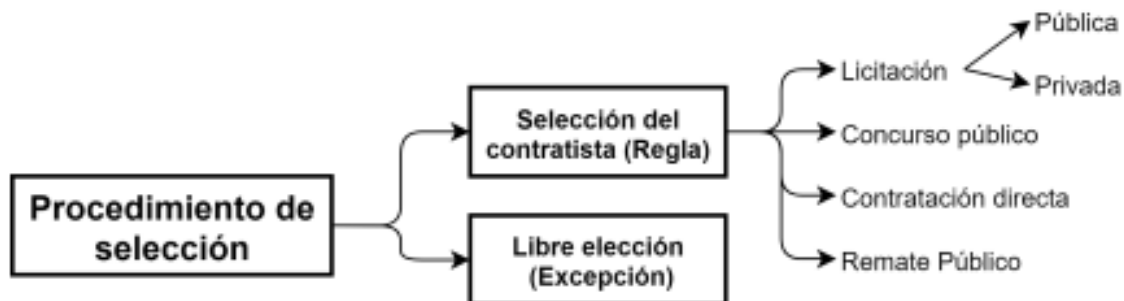
Art. 27. Habilitados para contratar:

1. Personas humanas o jurídicas
2. Que no se encuentren penalizadas con las sanciones de esta ley.
3. Incorporadas a la base de datos del órgano rector.

Art. 28. NO habilitados:

1. Personas sancionadas
2. Agentes y funcionarios, empresas con participación estatal mayoritaria.
3. Condenados por delitos dolosos (x2)
4. Procesados por delitos contra la propiedad, contra la Administración Pública, contra la fe pública, o de corrupción.
5. Personas que no cumplen con sus obligaciones tributarias y previsionales.
6. Empleadores que tienen sanciones laborales.

Procedimientos de selección del contratista



¿Quiénes pueden ser cocontratantes?

Pueden serlo las personas humanas, jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas dentro o fuera del territorio de la República, en cuanto estén encuadradas en las normas que regulan lo atinente a la contratación con el Estado. Los procedimientos a los que se recurre para seleccionar al cocontratante no son exclusivos de los contratos “administrativos” propiamente dicho porque también los contratos civiles de la Administración Pública pueden estar sometidos a esas exigencias, y porque tampoco es raro observar esas mismas prácticas en negociaciones celebradas entre los particulares.

Los medios o sistemas idóneos para la selección del cocontratante son:

1. Libre elección

Consiste en la posibilidad de que la Administración Pública elija directa y discrecionalmente a su cocontratante, sin tener que cumplimentar previamente algún requisito especial. Pero esa libre elección no significa “posibilidad irracional de elección”, pues también deberá ajustarse y respetar los criterios generales que delimitan su actuación.

2. Licitación

Consiste en un procedimiento de selección del cocontratante sobre la base de una previa justificación de idoneidad moral, técnica y financiera, para establecer qué persona o entidad es la que ofrece el precio más conveniente para la administración pública.

Uno de los presupuestos fundamentales de la licitación es la igualdad de trato.

Clases de licitación:

Se reconocen 2 especies fundamentales de licitación: la pública y la privada.

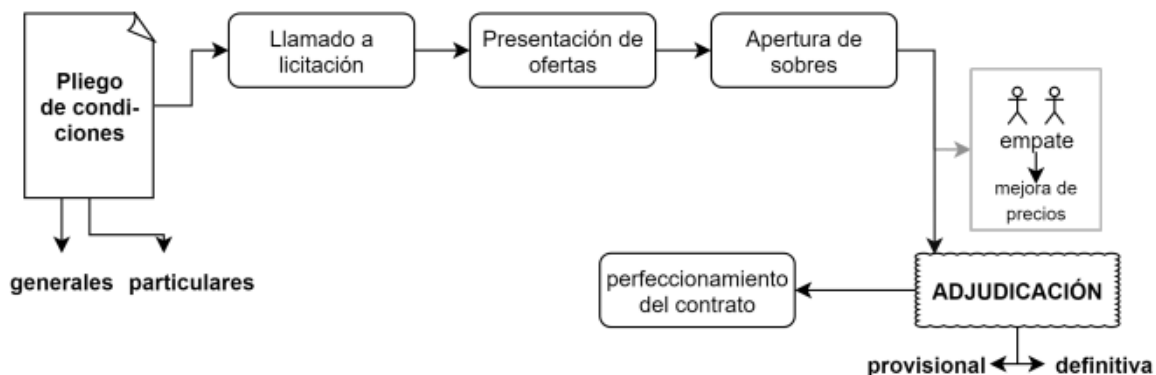
2.a. Licitación pública

La licitación pública es, en la legislación argentina, el procedimiento de principio para la contratación en la administración pública. Así lo establecen la ley de obras públicas 13.064 y el reglamento de contrataciones del Estado.

La licitación pública es un procedimiento administrativo cuya finalidad es seleccionar al sujeto de derecho con quien se celebrará un contrato; constituye un pedido de ofertas efectuado en forma general al público o a cualquier empresa inscripta en un registro creado el afecto, cuando tal sistema de control existe.

- Es obligatoria a partir de cierto monto.
- El número de oferentes o licitadores no tiene limitación.
- En el orden nacional pueden presentarse todas las personas o entidades inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado, en tanto la actividad y rubros que figuran en la inscripción se relacionen con el objeto del contrato a celebrar.
- Como excepción también pueden ser oferentes o licitadores las personas o entidades que, aún sin estar inscriptas en dicho registro, se hallan expresamente autorizadas por la ley.
- La licitación pública no es una "oferta" sino un pedido de ofertas, un llamado impersonal para que todos los que se encuentren en condiciones de hacerlo formulen ofertas para la contratación respectiva.

Procedimiento de licitación



Pliego de condiciones: Se ha definido como el conjunto de cláusulas redactadas por la Administración, especificando qué se licita, estableciendo las condiciones del contrato a celebrar y determinando el trámite a seguir en el procedimiento de licitación.

Hay **2 clases de pliegos de condiciones**: los **generales** y los **particulares**. Los **primeros** contienen reglas jurídicas válidas para todos los contratos de la Administración; los **segundos** fijan las condiciones específicas o particulares de cada contrato, completando así las disposiciones de los pliegos de condiciones de carácter "general".

El "pliego de condiciones", en cuanto expresa o traduce el contenido del contrato celebrado, es parte integrante del mismo.

2.b. Licitación privada

Es un pedido de ofertas, dirigido a personas o empresas determinadas (las que la administración invita especial y directamente para cada caso), no siendo obligatorio, en algunos casos, efectuar la publicación en el Boletín Oficial (B.O.), pero efectuando invitaciones a proveedores inscriptos en el registro de proveedores y difundiendo la convocatoria por internet en el sitio de la Oficina Nacional de Contrataciones.

- Se caracterizan por ser obras de un monto menor.
- No se exige la publicidad y en general deben ser invitadas al menos 6 personas (humanas o jurídicas).

3. Contratación directa

La Contratación Directa, según Dromi *“es el procedimiento por el cual el Estado elige directamente el co-contratante, sin concurrencia, puja u oposición de oferentes”*. Es decir, el Estado elige directamente al contratista sin previo concurso, no habiendo un procedimiento real de selección. Este procedimiento faculta a la administración a dirigirse libremente a quien juzgue conveniente y solicitar al mismo una oferta.

Esta modalidad de contratación, es una excepción a la regla general que rige en el sistema de contrataciones pública.

No debe confundirse el **sistema de contratación directa** con el **sistema de libre elección**. En este **último** se comprende todo tipo de contrato, en cambio la **contratación directa** es un sistema específico: procede para casos determinados y muchas veces es subsidiario, pues procede ante el fracaso de una **licitación**.

En el orden nacional la contratación directa procede:

1. Cuando el costo de la obra no exceda de 3 millones de pesos tratándose de una obra pública, o cuando la operación no exceda de \$100.000 tratándose de contratos que prevé el decreto ley de contabilidad.
2. Cuando se trate de trabajo suplementarios en una obra en curso.
3. Casos de urgencia o circunstancias imprevistas.

4. Cuando resulta determinante la capacidad científica, artística, destreza, o cuando el ejecutor se halle amparado por patente.
5. Cuándo realizada la licitación no haya habido proponente o no se hubiere hecho oferta admisible.
6. Cuándo se trate de compra de inmuebles en remate público.
7. Cuando existe escasez en el mercado local de los bienes adquirir (tiene que ser acreditado).
8. Contrataciones entre reparticiones públicas.
9. Venta de productos perecederos y elementos destinados al fomento de actividades económicas del país o para satisfacer necesidades de orden sanitaria.
10. Reparación de vehículos y motores.
11. La compra de semovientes por selección.
12. Universidades nacionales: la ley orgánica establece que pueden contratar en forma directa las adquisiciones de material docente, científico y bibliográfico hasta la suma, en los casos y con las formalidades dispuestas en la ley (Éstas constituyen excepciones al régimen de contrataciones del Estado).

4. Remate público

Consiste en la venta de bienes, en público, al mejor postor. No hay selección de concurrentes: concurre quien desea hacerlo.

La Administración puede intervenir en un remate como vendedora o como compradora.

En el primer caso debe ser efectuado por oficinas estatales especializadas en la materia, mientras que, si actúa como compradora, el remate público lo realiza cualquier entidad, sea pública estatal o una persona particular, individual o jurídica.

5. Concurso

Es la oposición que se realiza para determinar la mayor capacidad técnica, científica, cultural o artística entre dos o más personas.

Si bien tanto en el concurso, licitación y remate, aparece el factor concurrencia (oposición entre los candidatos), el concurso tiene la particularidad de ponderar principalmente el factor personal, mientras que los otros casos se consideran las condiciones técnicas y financieras. El concurso se vincula más a lo intelectual,

científico o artístico, por lo que es muy utilizado en los contratos estrictamente intuitu personae.

Contrato de obra pública

Obra pública y contrato de obra pública son nociones distintas entre sí. La "obra" es un bien que crea la actividad humana. ***Obra "pública" es aquella en cuya creación o realización interviene -directa o indirectamente- el Estado.*** En cambio, el contrato de obra pública es una de las formas o maneras en que la obra puede realizarse.

¿Qué se entiende por "obra pública"?

Por tal ha de entenderse el bien construido o realizado por el Estado, directa o indirectamente.

→ Se habla de "bien" porque la obra pública puede consistir o referirse a muebles, inmuebles y objetos inmateriales.

→ Ese bien ha de ser construido por el Estado directa o indirectamente: a la obra puede efectuarla el Estado, por sí o a través de terceros (contratantes o concesionarios).

→ Puede tratarse tanto de cosas de dominio público, como de dominio privado del Estado.

→ Puede darse a través de un contrato "administrativo" stricto sensu o un contrato de der. privado de la AP. Todo depende de la índole de las funciones o fines que el Estado cumplirá o satisfará a través de la obra pública.

→ Toda "obra pública" es resultado de un "trabajo público" Puede consistir en trabajos de construcción de la obra, como su mantenimiento, su reparación o su modificación. Pueden consistir en la destrucción de una cosa Ej, demolición de edificios.

Procedimiento de contratación

Para realizar una obra pública valiéndose de la colaboración de terceros, el Estado puede recurrir al "contrato" administrativo de obra pública o a la "concesión" de obra pública:

Contrato de obra pública	Concesión de obra pública
---------------------------------	----------------------------------

La relación contractual vincula exclusivamente a la Administración Pública y al cocontratante. Este último ejecuta la obra y cobra el precio a la AP, con lo cual queda extinguido el vínculo contractual. (paga la Administración Pública)	El vínculo excede el exclusivo ámbito de la Administración Pública – concesionario, extendiéndose a ciertos administrados, quienes, en determinadas formas (peaje y contribución), deben pagarle al concesionario el precio de la obra (surte efectos hacia 3ros). (paga el particular)
---	---